

第3節 有価証券偽造の罪 第4節 支払用カード電磁的記録に関する罪 第5節 印章偽造の罪

第4章 風俗に対する罪

刑法
No.388

H20-2

(配点: 2)

月 日
月 日

次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 甲は、自己が経営する書店においてわいせつ図画である写真誌を販売するに当たり、当該写真誌をビニールで包装して、わいせつ性のない表紙だけが閲覧できるようにして陳列していた。この場合、甲には、わいせつ物有償頒布目的所持罪は成立しない。(改)
2. 甲は、人通りの多い道路上で、自己の陰部を露出させたが、偶然にも、通行人はだれもそれに気付かなかった。この場合、甲には、公然わいせつ罪は成立しない。
3. 書籍の通信販売業を営んでいた甲は、日本語で書かれたわいせつ文書である小説を、外国語で書かれているかのように装って複数の外国人に販売したが、これを購入した顧客はいずれも日本語の読解能力に乏しかったため、その小説の内容を理解することができなかった。この場合、甲には、わいせつ物頒布等罪は成立しない。(改)
4. 甲は、友人の乙が誕生日を迎えることを知り、わいせつ図画であるDVD1枚を購入した上、これをお祝いとして乙にプレゼントした。この場合、甲には、わいせつ物頒布等罪は成立しない。(改)
5. 甲は、公園内において、多くの人が見ている前で、乙に対し、その衣服全部をはぎ取るなどして強いてわいせつな行為をした。この場合、甲には、不同意わいせつ罪が成立するが、公然わいせつ罪は成立しない。(改)

1 誤っている

本記述では、わいせつ図画である写真誌をビニールで包装して、わいせつ性のない表紙だけが閲覧できるようにしても、なお右写真誌が「わいせつな……図画」(175条2項・1項)に当たるかが問題となる。この点については、いかに嚴重に封をされた包みの中にあると、象形的方法により表示され、人が認識し得る状態にある限り、わいせつな写真は「わいせつな……図画」に当たるとされている。最高裁判例では、わいせつ性を除去するために性器等を黒く塗りつぶしても、インクを容易に除去し得る場合には「わいせつな……図画」に当たるとしたものがある(最判昭58.3.8)。この判例から考えても、本記述におけるビニール包装の写真誌は「わいせつな……図画」に当たると解される。また、175条2項の「所持」とは、わいせつ物を自己の事実上の支配下に置くことをいい、現に握持している必要はない。そのため、本記述のように、自己が経営する書店において販売する目的で写真誌を陳列していた甲は、わいせつな図画を「有償で頒布する目的」で「所持」していたといえる。よって、甲にはわいせつ物有償頒布目的所持罪(175条2項)が成立する。

2 誤っている

判例は、公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいうとしており(最決昭32.5.22)、不特定であれば少数でも、あるいは多数であれば特定の人の集団でも「公然」の要件を満たす。そしてそれらの者がわいせつ行為を現実に認識する必要はなく、認識する可能性があれば足りる。本記述では、甲は、人通りの多い路上という不特定又は多数人が認識できる状況下で、陰部の露出というわいせつな行為を行っているから、たとえ通行人が誰も気付かなかったとしても、甲には公然わいせつ罪(174条)が成立する。

3 誤っている

わいせつ物頒布等罪(175条1項)の「わいせつな文書」といえるためには、販売された文書が客観的にわいせつ性を有していれば足り、購入者がわいせつ性を理解できる必要はないと解される。同罪は社会法益たる風俗秩序を害する罪であるところ、客観的にわいせつ性を有する文書が販売されれば風俗秩序は害されたといえるからである。したがって、甲から小説を購入した外国人がそのわいせつ性を理解できなくても、本記述の甲には、わいせつ物頒布等罪(175条1項)が成立する。

4 正しい

わいせつ物頒布等罪(175条1項)における「頒布」とは、不特定又は多数の者に有償又は無償で交付することをいう。不特定又は多数の者に行う意思(反復継続の意思)があれば、特定かつ少数の者に対するものであっても、「頒布」に当たる(大判大6.5.19)。しかし、特定人に対する1回限りの交付は「頒布」に当たらない。なぜなら、不特定又は多数の者に対して交付される場合にわいせつ物が広範囲に伝播される危険性が認められるからである。本記述では、甲は、乙という特定人に対し、誕生日プレゼントとして1回限りでわいせつ図画であるDVDを交付したのであり、不特定又は多数の者に行う意思(反復継続の意思)なく特定かつ少数の者に交付しており、「頒布」とはいえない。したがって、甲にはわいせつ物頒布等罪は成立しない。

5 誤っている

本記述では、甲が、公園内において、多くの人が見ている前で、乙に対し、その衣服全部をはぎ取るなどして強いてわいせつな行為をしており、かかる行為について、不同意わいせつ罪(176条)及び公然わいせつ罪(174条)が成立するか否かが問題となる。まず、甲は強いて乙にわいせつな

行為を行っているので、甲の行為は不同意わいせつ罪の「わいせつな行為」に該当する。また、甲は、公園内において多くの人が見ている前でわいせつな行為をしているので、「公然とわいせつな行為をした」(174条)といえる。そして、このように不同意わいせつ罪を公然と犯した場合について、判例は、強制わいせつ罪〔現：不同意わいせつ罪〕と公然わいせつ罪がともに成立し、観念的競合となるとしている(大判明 43.11.17)。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、不同意わいせつ罪は個人の性的自由・感情を保護法益とするのに対し、公然わいせつ罪は性的風俗を保護法益とし、両罪の保護法益が異なるということを挙げている。